

律师办理劳务派遣合同纠纷案件业务操作指引（2026）（试行）

发 文 机 关：上海市律师协会

发 布 日 期：2026. 04. 13

生 效 日 期：2026. 04. 13

时 效 性：现行有效

目 录

第一章 总则

第二章 劳务派遣法律关系的界定

第三章 劳动合同和劳务派遣协议的订立

第四章 劳务派遣的履行和变更

第五章 被派遣劳动者的退回

第六章 劳动合同的解除和终止

第七章 劳务派遣争议案件代理

第八章 附则

律师办理劳务派遣合同纠纷案件业务操作指引（2026）（试行）

第一章

总 则

第一条 为指导律师依法履行职责，提高律师办理劳务派遣案件的业务能力，为律师办理劳务派遣法律业务提供参考，维护当事人的合法权益及防范执业风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》以及相关法律、法规等规定，制定本指引。

第二条 劳务派遣制度的核心功能在于满足用工单位灵活用工需求与保障被派遣员工合法权益，其主要方式为通过规范劳务派遣单位、用工单位与被派遣劳动者三方之间的权利义务关系，实现三者之间的权益均衡。

第三条 本指引的制定为律师规范办理劳务派遣案件提供了借鉴，对于维护用工单位灵活高效的用工机制、保障被派遣员工的平等权利与福利待遇、指导律师厘清不同法律关系中的责任承担、促进劳动力市场的有序流动和健康发展等方面具有重要意义。

第四条 在劳务派遣用工管理过程中，应更加注重平衡劳务派遣法律关系中的各方利益，强调用工岗位、比例、薪酬及社会保险等方面的合规性与可操作性，并适应新就业形态和灵活用工市场的发展变化，通过推动劳务派遣制度的规范化与健康化发展，为用工单位灵活用工、被派遣员工劳动权益保障以及人力资源市场有序运行提供更加坚实的制度支持。

第五条 代理劳务派遣相关案件除严格依据法律法规规定外，还应全面关注涉及劳务派遣的部门规章、地方性政策、类案裁判标准及最新司法动态。由于不同地区对劳务派遣的“三性”岗位认定、用工比例、同工同酬原则的具体实施存在差异，且司法实践持续发展更新，尤其是当案件涉及跨地区用工、派遣单位与用工单位分属不同地域时，律师必须准确把握用工所在地及案件审理地的具体裁判规则和政策口径，以避免因地域司法实践不统一而导致法律适用偏差和策略失误。

第六条 本指引所称劳务派遣案件，是指律师向当事人提供的涉及用工单位、派遣单位与被派遣员工之间因劳务派遣关系产生的非诉讼和诉讼法律服务。具体法律服务包括但不限于律师通过法律咨询、合同审查与代写、合规方案设计、用工模式论证、背景调查、纠纷调解以及代理参加仲裁和诉讼等方式。

第七条 本指引主要从劳务派遣法律关系的界定、劳动合同和劳务派遣协议的订立、劳务派遣的履行与变更、被派遣劳动者的退回、劳动合同的解除和终止和劳务派遣争议案件的代理等方面进行阐述，并附相关法律法规依据、指导性案例和典型案例供参考。

第二章

劳务派遣法律关系的界定

第八条 律师应告知劳务派遣单位在从事劳务派遣业务时，应符合如下规定要求：

- （一）派遣单位持有合法有效的《劳务派遣经营许可证》；
- （二）派遣单位与被派遣劳动者已签订书面劳动合同，合同期限不少于二年；

（三）派遣单位与用工单位已签订书面劳务派遣协议，协议载明派遣岗位、派遣期限、劳动报酬及社会保险费支付方式、违反协议的责任等内容；

（四）被派遣劳动者在用工单位的工作时间、工作方式、劳动纪律、考核标准等由用工单位直接决定；

（五）派遣单位依法向劳动者支付工资，并为其缴纳社会保险费；

（六）用工单位以“人/月/单价”或类似方式向派遣单位支付派遣费用。

第九条 律师应提示劳务派遣单位和用工单位，若无劳务派遣许可证虽不直接否定劳务派遣关系，但会产生行政处罚，且用工单位需承担相应责任。

第十条 律师应告知用工单位，在通过劳务派遣方式用工时，劳务派遣的具体岗位应符合规定下列要求：

临时性岗位：存续时间不超过六个月，起止日期须在劳务派遣协议中明确，并与项目订单、专项任务书、阶段性生产经营计划等佐证材料保持一致。

辅助性岗位：系为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位。律师应提示用工单位履行下列程序：

- （一）编制辅助性岗位目录草案；
- （二）经职工代表大会或全体职工讨论，提出意见；
- （三）与工会或职工代表平等协商确定；
- （四）在单位内公示不少于五个工作日；
- （五）报所在地人力资源社会保障行政部门备案。

替代性岗位：因用工单位的劳动者脱产学习、休假、工伤（职业病）医疗期、女职工“三期”等原因，无法提供劳动的期间内设置的岗位。替代性岗位的期限应根据原岗位劳动者无法提供劳动的实际合理期间确定。

第十一条 律师应查阅用工单位提供的职工代表大会会议纪要、公示照片、备案回执、医院病假单、入伍通知书、学校录取通知书等证据。

第十二条 律师应告知用工单位使用被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。律师应协助用工单位按所在地要求向所在地人力资源社会保障行政部门报送《劳务派遣用工情况年度报告表》，并留存报送回执、系统截图或快递签收单等材料。对于集团公司、关联企业共用派遣员工、共享服务中心等复杂情形，律师应当提示用工单位按照“谁用人、谁统计”的原则分别计算，并准备集团内部派遣协议、人员划转单、工资分摊表等证据，防止被认定为规避比例监管。

第十三条 律师应提示外国企业常驻代表机构和外国金融机构驻华代表机构等使用被派遣劳动者，以及船员用人单位以劳务派遣形式使用国际远洋海员的，不受“三性”岗位和用工比例的限制。律师应当核查用工单位提供的营业执照、行业许可证、政府指令文件、任务委托书等，并出具是否适用例外情形的专项法律意见。

第十四条 律师应告知用工单位，在采用劳务派遣用工方式时，不得出现以下情形，并书面提示可能产生的法律风险：

- （一）在非临时性、非辅助性、非替代性岗位上使用被派遣劳动者；
- （二）将连续用工期限拆分为数个短期派遣协议，规避“三性”限制；
- （三）再派遣、转派遣、自我派遣、关联企业相互派遣；
- （四）以实习、见习、外包、人事代理、共享用工、平台用工、灵活用工等名义掩盖劳务派遣实质；
- （五）向被派遣劳动者收取任何形式的押金、保证金、介绍费、培训费、服装费、资料费、体检费等费用，扣押居民身份证、毕业证、技能证书等证件；
- （六）安排被派遣劳动者从事具有职业病危害的作业未依法进行职业健康检查；安排未取得特种作业操作证的人员从事特种作业；
- （七）法律法规、部门规章以及地方性法规规定的其他情形。

第十五条 律师在区分劳务派遣与劳务外包时，建议根据下列要素进行综合判断，不以合同名称或表面形式作为唯一依据：

- （一）主体资质：劳务派遣须取得《劳务派遣经营许可证》；外包单位如仅从事人力资源服务外包，不涉及特许业务，无需行政许可，但须向所在地人力资源社会保障行政部门备案。
 - （二）岗位要求：劳务派遣只能在“三性”岗位实施；外包无岗位限制，可为主营业务。
 - （三）管理权限：劳务派遣由用工单位直接对劳动者实施指挥、考勤、考核、奖惩；外包由外包单位对劳动者实施全部人事管理，发包单位仅对工作成果进行验收。
 - （四）费用结算：被派遣劳动者的工资、社会保险由劳务派遣单位代发代缴，仅将管理费作为营业收入；外包以“工作数量×单价”或“工作成果”计费，劳动者的工资、社会保险由外包单位负责。
- 律师应提示当事人：费用结算是区分劳务派遣与外包的重要参考因素，但非决定性要件。决定性因素在于用工单位是否直接对劳动者进行指挥管理，若用工单位直接管理劳动者的仍可能被认定为劳务派遣。
- （五）风险承担：劳务派遣中用工风险，如用工单位给劳动者造成损失的，由劳务派遣单位与用工单位承担连带责任；外包中劳动用工风险由外包单位独立承担责任。
 - （六）适用法律：劳务派遣主要适用《劳动合同法》《劳务派遣行政许可实施办法》《劳务派遣暂行规定》；外包主要适用《民法典》。
 - （七）纳税方式：劳务派遣适用差额征税，仅管理费需要纳税；外包适用全额征税。

第十六条 律师应告知发包单位采用劳务外包的用工方式时，若对外包单位劳动者实施下列任一行为，存在被裁审机构认定实施直接管理行为属于“假外包、真派遣”的情形：

- （一）直接制定、发布、修改劳动者的工作任务、工作时间、工作地点、劳动纪律；
- （二）直接向劳动者发布指令、考核、奖惩决定；
- （三）直接为劳动者提供工作证件、门禁卡、工作邮箱、工位、工具设备、劳保用品；
- （四）直接对劳动者进行考勤、请销假审批、绩效考核、薪酬调整；
- （五）以发包单位名义对外出具劳动者的工作成果；
- （六）费用结算以“人头费”“人/月/单价”为主，而非以“工作量/工作成果”为主。

第十七条 律师应提示委托人，若劳务外包被认定为“假外包、真派遣”的，此时发包方实际为用工单位，将面临以下风险：

- （一）连带赔偿责任：依据《劳动合同法》第九十二条，用工单位与派遣单位对劳动者损害承担连带责任；
- （二）行政处罚：人力资源社会保障行政部门可责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款；
- （三）违法退回责任：用工单位违法退回被派遣劳动者的，需继续履行合同或支付赔偿金；
- （四）工伤保险责任：用工单位应协助工伤认定，派遣单位承担工伤保险责任，但双方可约定补偿办法；
- （五）同工同酬责任：未实行相同报酬分配办法的，责令限期整改并处罚款；
- （六）诉讼地位：仲裁、诉讼中被列为共同当事人。

第十八条 律师应告知委托单位不得以人事代理之名行劳务派遣之实，服务机构不得与劳动者签订劳动合同，不得向劳动者支付工资，不得对劳动者实施指挥管理。律师审查人事代理协议时，应重点核查：

- （一）合同名称、费用构成（代理服务费等不得与工资、社保费挂钩）；
- （二）服务机构经营范围是否包含“人事代理”；
- （三）工资支付主体、社保缴纳主体是否为委托单位；
- （四）劳动者是否接受委托单位直接管理。

第十九条 律师在接受委托时建议制作《劳务派遣法律关系审查清单》，对下列事项逐项核查并留存书面或电子证据：

- （一）派遣单位营业执照、许可证正副本；
- （二）劳动合同、劳务派遣协议、补充协议、变更协议；
- （三）辅助性岗位民主程序会议纪要、公示照片、备案回执；
- （四）用工总量计算表、年度报告及回执；
- （五）工资支付凭证、社保缴费凭证、个税申报记录；
- （六）考勤记录、绩效考核表、工作指令、交接清单、成果验收单；
- （七）外包或人事代理的投标文件、中标通知书、外包合同、工作量确认单、发票、付款凭证；
- （八）消防、安全生产、产品质量、工作场所秩序等管理制度及培训记录。

部分地区可能还要求《劳务派遣经营许可证》在注册地以外的地区开展业务时，还需进行跨地区备案。《劳务派遣行政许可实施办法》规定了《劳务派遣经营许可证》3年有效期及延期许可。律师应提示当事人，关注许可证是否在有效期内。

第二十条 律师在案件结案时，建议在结案报告中就法律关系界定、合规风险、整改建议出具专项意见，并告知当事人保存期限不得少于三年。对于重大风险事项，建议律师同时抄送用人单位法务、合规或内审等相关部门。

第三章

劳动合同和劳务派遣协议的订立

第二十一条 律师应提示劳务派遣单位及时与被派遣劳动者签订书面劳动合同，并与用工单位签订劳务派遣协议。律师在受托范围内可提供起草、审核修订等非诉法律服务。

第二十二条 律师为劳务派遣单位提供劳动合同的起草、审核修订等法律服务时，应注意劳动合同内容至少应载明以下事项：

- （一）劳务派遣单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；
- （二）被派遣劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效证件号码；
- （三）劳动合同期限；
- （四）工作内容和工作地点；
- （五）工作时间和休息休假；
- （六）劳动报酬；
- （七）社会保险；
- （八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
- （九）被派遣劳动者的用工单位；
- （十）派遣期限；
- （十一）工作岗位；
- （十二）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

第二十三条 劳务派遣单位与被派遣劳动者的劳动合同中除上述应当载明的内容外，劳动合同中亦可载明以下事项：

- （一）被派遣劳动者遵循劳务派遣单位及用工单位的规章制度等；
- （二）劳动合同的解除和终止；
- （三）工作交接；
- （四）其他。

第二十四条 律师接受委托为劳务派遣单位提供与劳动合同订立有关的非诉法律服务时，应注意以下合规要点：

（一）劳务派遣用工要求：只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，且劳务派遣用工比例不得超过用工单位的用工总量的 10%。

（二）劳动合同期限：可以订立无固定期限劳动合同或者固定期限劳动合同，订立固定期限劳动合同的，固定期限劳动合同至少为两年。劳务派遣单位不得与被派遣劳动者签订以完成一定任务为期限的劳动合同，不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者。

（三）被派遣劳动者：劳务派遣单位不得招用未满 16 周岁的未成年人，不得派遣在校学生实习。

（四）劳动合同试用期：劳务派遣单位可以依法与被派遣劳动者约定试用期，但与同一被派遣劳动者只能约定一次试用期。

（五）劳动合同变更：对派遣岗位等有所调整时，劳务派遣单位应取得被派遣劳动者的同意。

（六）劳动报酬支付：劳动派遣单位应当足额将与用工单位协商一致的劳动报酬全额支付给劳动者，不得克扣或减少发放。被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位仍应当按照所在地的职工最低工资标准，向其按月支付报酬。

（七）其他协议：用工单位可与被派遣劳动者另行签订其他协议，包括但不限于保密协议、服务期协议、竞业限制协议等。

第二十五条 律师应提示劳务派遣单位及时与被派遣劳动者签订书面劳动合同，未及时签订书面劳动合同会导致被派遣劳动者选择确认与用工单位存在劳动关系及主张未签订书面劳动合同支付双倍工资差额的法律风险。

第二十六条 律师应提示劳务派遣单位以劳动合同或附件等形式将劳务派遣内容告知被派遣劳动者，具体包括：

- （一）被派遣劳动者工作内容；
- （二）工作条件；
- （三）工作地点；
- （四）职业危害；
- （五）安全生产状况；
- （六）劳动报酬；
- （七）应遵守的规章制度；
- （八）劳务派遣协议内容及其他被派遣劳动者要求了解的情况。

第二十七条 律师接受委托提供与劳务派遣协议相关的非诉法律服务时，应注意协议内容应载明以下主要事项：

- （一）派遣的工作岗位名称和岗位性质；
- （二）工作地点；
- （三）派遣人员数量和派遣期限；
- （四）按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式；
- （五）社会保险费的数额和支付方式；
- （六）工作时间和休息休假事项；
- （七）被派遣劳动者工伤、生育或者患病期间的相关待遇；
- （八）劳动安全卫生以及培训事项；
- （九）经济补偿等费用；
- （十）劳务派遣协议期限；
- （十一）劳务派遣服务费的支付方式和标准；
- （十二）违反劳务派遣协议的责任；
- （十三）法律、法规、规章规定应当纳入劳务派遣协议的其他事项。

第二十八条 劳务派遣协议除上述应当载明的内容外，协议中亦可载明以下事项：

- （一）劳务派遣单位与用工单位各自的权利义务；

- （二）被派遣劳动者的聘用程序；
- （三）劳务派遣用工关系的解除和终止；
- （四）违约责任及争议解决方式；
- （五）其他。

第二十九条 律师接受委托提供与劳务派遣协议相关的非诉法律服务时，应注意以下合规要点：

（一）派遣期限：用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议；派遣期限不应超过劳务派遣单位与被派遣劳动者之间的劳动合同期限。

（二）同工同酬：参照用工单位所在地标准，与用工单位同类岗位实行相同的劳动报酬标准，不得区别对待被派遣劳动者。否则可能会被人力资源社会保障行政部门责令限期整改、予以处罚。

（三）工伤处理：用工单位在知道或者应当知道工伤事故发生后及时通知劳务派遣单位并协助劳务派遣单位共同处理工伤相关事宜。工伤保险基金之外的相关费用通过协议方式约定由用工单位承担。

（四）劳务派遣单位与用工单位用工责任的承担：

1. 因劳务派遣单位未及时与被派遣劳动者订立劳动合同产生的未签订书面劳动合同的双倍工资差额支付义务由劳务派遣单位自行承担。

2. 因解除劳动关系产生的相应经济补偿或赔偿责任按约定执行，未约定情形通常是劳务派遣单位先行支付，后由劳务派遣单位向用工单位追偿。因劳务派遣单位未依据协议未及时足额支付劳动报酬、未依法缴纳社会保险费的情况导致被派遣劳动者依据劳动合同法第三十八条提出解除劳动合同的，产生经济补偿责任等由劳务派遣单位承担。

第三十条 律师接受委托提供劳务派遣法律服务时，如发现劳务派遣单位未取得行政许可的，应及时提示所签订的劳务派遣协议会被判定无效的法律风险，但劳务派遣协议被判无效前劳务派遣单位、用工单位、被派遣劳动者已经履行的权利义务可依照原协议和实际履行的内容确定。

第三十一条 律师应告知劳务派遣单位，《劳务派遣经营许可证》有效期满未延续或被撤销、吊销的，原订立的劳动合同和劳务派遣协议可继续履行至派遣期限届满。

第四章

劳务派遣的履行和变更

第三十二条 律师应告知劳务派遣单位作为用人单位，应当对被派遣劳动者履行下列义务：

（一）如实告知被派遣劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、应遵守的规章制度、劳务派遣协议内容以及被派遣劳动者要求了解的其他情况；

（二）建立培训制度，对被派遣劳动者进行上岗知识、安全教育培训；

（三）按照国家规定和劳务派遣协议约定，依法支付被派遣劳动者的劳动报酬和相关待遇，不得克扣被派遣劳动者的劳动报酬，不得向被派遣劳动者收取费用；被派遣劳动者在无工作期间，应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准向其按月支付报酬；

（四）按照国家规定和劳务派遣协议约定，依法为被派遣劳动者缴纳社会保险费，并办理社会保险相关手续；

- （五）督促用工单位依法为被派遣劳动者提供劳动保护和劳动安全卫生条件；
- （六）依法出具解除或者终止劳动合同的证明；
- （七）协助处理被派遣劳动者与用工单位的纠纷；
- （八）法律、法规和规章规定的其他事项。

第三十三条 律师应告知用工单位应当对被派遣劳动者履行下列义务：

- （一）告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；
- （二）支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇，不得歧视被派遣劳动者；
- （三）连续用工的，实行正常的工资调整机制；
- （四）保障被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，无同类岗位劳动者的，参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定；
- （五）执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；
- （六）对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；
- （七）不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位；
- （八）保障被派遣劳动者选择在用工单位依法参加或者组织工会的权利。

第三十四条 律师应告知劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，应当按照用工单位所在地的标准执行，即以“劳动合同履行地”原则执行有关标准。

劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，应当在用工单位所在地为被派遣劳动者参加社会保险，按照用工单位所在地的规定缴纳社会保险费，被派遣劳动者按照国家规定享受社会保险待遇。

劳务派遣单位在用工单位所在地设立分支机构的，由分支机构为被派遣劳动者办理参保手续，缴纳社会保险费。劳务派遣单位未在用工单位所在地设立分支机构的，由用工单位代劳务派遣单位为被派遣劳动者办理参保手续，缴纳社会保险费。

劳务派遣单位未在用工单位所在地设立分支机构且用工单位未按规定代劳务派遣单位为被派遣劳动者在用工单位所在地办理参保手续、缴纳社会保险费，导致被派遣劳动者无法享受社会保险待遇的，劳务派遣单位与用工单位可能承担连带责任，上海地区被派遣劳动者可以要求本市用工单位先行承担工伤、医疗等社会保险待遇。

第三十五条 律师应告知劳务派遣单位和用工单位，被派遣劳动者发生工伤时，应按照下列情形处理：

- （一）被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，并承担申请工伤劳动能力鉴定、申领工伤保险待遇等工伤保险责任；用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。劳务派遣单位跨地区派遣劳动者且劳务派遣单位未在用工单位所在地设立分支机构的，则由用工单位提出工伤认定申请。
- （二）被派遣劳动者在申请进行职业病诊断、鉴定时，用工单位应当负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料，劳务派遣单位应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的其他材料。

（三）被派遣劳动者在用工单位发生工伤的，一般由劳务派遣单位承担工伤保险责任，但可以与用工单位约定补偿办法。在上海地区，则由用工单位承担应当由用人单位支付的工伤保险待遇及浮动费率等工伤保险责任，由劳务派遣单位对用工单位的工伤保险责任依法承担连带赔偿责任。

第三十六条 律师应告知劳务派遣单位和用工单位，双方应当按照国家规定和劳务派遣协议约定各自履行对被派遣劳动者的义务，并承担相应的法律责任。对用工单位违反有关劳务派遣的规定，给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。

第三十七条 律师应告知劳务派遣单位和用工单位，经协商一致，双方及被派遣劳动者可变更劳务派遣协议内容以及劳动合同内容，亦可更换劳务派遣单位或变更用工单位。更换劳务派遣单位或变更用工单位的，应尽量采用书面形式就工作年限承继、劳动报酬结算、带薪年假折算等权利义务约定清楚。

劳务派遣单位和用工单位将派遣用工转为人力资源服务外包的，应当调整原劳务派遣法律关系所形成对劳动者的管理方式，根据人力资源服务外包的性质，参照直接管理和间接管理的原则合理确定管理界限，防止引发相关纠纷。用工单位应避免以承揽、外包等名义，实际按照劳务派遣用工形式使用劳动者，防止“假外包、真派遣”。

第五章

被派遣劳动者的退回

第三十八条 律师应当告知用工单位，在被派遣劳动者符合退回的法定情形时，可以将被派遣劳动者退回至劳务派遣单位。在退回时，用工单位应当就退回的事实证据与理由通过书面形式向劳务派遣单位充分说明。

第三十九条 律师应当告知用工单位，被派遣劳动者存在下列情形的，可以被退回：

- （一）被派遣劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；
- （二）被派遣劳动者严重违反用工单位的规章制度的；
- （三）被派遣劳动者严重失职，营私舞弊，给用工单位造成重大损害的；

（四）被派遣劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用工单位提出，拒不改正的；

（五）被派遣劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同无效的；

- （六）被派遣劳动者被依法追究刑事责任的；

（七）被派遣劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用工单位另行安排的工作的；

- （八）被派遣劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

第四十条 律师应当告知用工单位，用工单位存在下列情形的，可以退回被派遣劳动者：

（一）劳务派遣协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

- （二）用工单位依照企业破产法规定进行重整的；

- （三）用工单位生产经营发生严重困难的；

（四）用工单位转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

（五）用工单位其他因劳务派遣协议订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的；

（六）用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的。

第四十一条 律师应当告知用工单位，劳务派遣协议期满终止时，用工单位可依法退回被派遣劳动者，但应提前通知劳务派遣单位及被派遣劳动者。

第四十二条 律师应当告知用工单位，依据下列情形之一的，也可退回劳动者：

（一）《劳动合同法》第四十四条第（一）、（二）项规定的情形；

（二）《劳动合同法实施条例》第二十一条规定的情形；

（三）派遣期限届满的；

（四）劳务派遣协议解除的；

（五）三方事前约定或者事后达成合意的（但需充分考虑劳务派遣单位所在地及/或被派遣劳动者劳动合同履行地的裁审实践）；

（六）用工单位不履行义务，派遣单位主动撤回劳动者的；

（七）依据《劳务派遣暂行规定》第十六条规定，派遣单位在办理注销登记手续前，用工单位与派遣单位协商后退回的；

（八）违反法律规定派遣进行整改的；

（九）其他依据法律规定确需退回的。

第四十三条 律师应当告知劳务派遣单位，被派遣劳动者退回后，被派遣劳动者与用工单位的用工关系终止，但其与劳务派遣之间的劳动关系并不当然解除或终止。

第四十四条 律师应当告知用工单位，被派遣劳动者有下列情形之一的，在派遣期限届满前，用工单位不得按照上述第二条第（一）至（五）项情形将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：

（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医疗观察期间的；

（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；

（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；

（五）在单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

第四十五条 律师应当告知用工单位，不得以劳务派遣单位未依法取得《劳务派遣经营许可证》、劳务派遣用工超过本单位用工10%的比例上限、超出“三性”岗位范围用工等为由，将被派遣劳动者退回至劳务派遣单位。

第四十六条 律师应当告知用工单位，如违法退回的，将面临由人力资源和社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款；给被派遣劳动者造成损害的，与劳务派遣单位承担连带赔偿责任的法律风险。

第四十七条 律师应告知劳务派遣单位，被派遣劳动者退回后，劳务派遣单位与劳动者的劳动关系仍然存续，并有权根据不同的事实与理由，做出如下处理：

（一）如劳动者符合解除劳动合同的条件，劳务派遣单位有权按照与用工单位退回通知中相同的理由与劳动者解除劳动关系；

（二）如劳动者不符合解除劳动合同的条件，或者劳务派遣单位拟将劳动者派遣至其他用工单位但暂无合适岗位的，劳务派遣单位有权要求被退回人员遵守劳务派遣单位规章制度，接受劳务派遣单位的管理。

第四十八条 律师应提示劳务派遣单位，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。若能安排被派遣劳动者至其他用工单位工作，需与其协商一致变更工作地点、岗位等内容，并书面确认；若无法安排工作，应按照不低于劳动合同履行地最低工资标准，向劳动者按月支付报酬。

如被派遣劳动者处于“三期”内被退回的，除适用《劳务派遣暂行规定》外，还应当按照《女职工劳动保护特别规定》第五条的规定，在其待岗期间按照其正常出勤情况下劳动合同约定的标准支付报酬，确保“三期”内女性被派遣劳动者不因怀孕、生育、哺乳降低工资。

第六章

劳动合同的解除和终止

第四十九条 律师应告知劳务派遣单位，劳务派遣单位与被派遣劳动者协商一致的，可以解除劳动合同。派遣单位行政许可有效期未延续或者《劳务派遣经营许可证》被撤销、吊销的，已经与劳动者依法订立的劳动合同应当履行至期限届满。双方经协商一致，可以解除劳动合同。

第五十条 律师应告知劳务派遣单位及用工单位，有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：

（一）被派遣劳动者提前三十日以书面形式通知劳务派遣单位，或在试用期内提前三日通知劳务派遣单位的；

（二）劳务派遣单位或用工单位有《劳动合同法》第三十八条规定的情形之一的；

（三）被派遣劳动者因《劳务派遣暂行规定》第十二条规定被用工单位退回，劳务派遣单位重新派遣时降低劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的。

也有观点认为，被派遣劳动者被退回依据不足，且劳务派遣单位未在合理期限内（一般为一个月）进行合理重新派遣的，被派遣劳动者参照《劳动合同法》第三十八条规定解除劳动合同并要求支付经济补偿的，劳动争议处理机构应予支持。但鉴于该观点仅为司法实务观点，并无明确法律条款支持，律师在向当事人提供法律意见时需审慎提供。

第五十一条 律师应告知劳务派遣单位，有下列情形之一的，劳务派遣单位可以解除劳动合同：

（一）被派遣劳动者有《劳动合同法》第三十九条规定情形之一的；

（二）被派遣劳动者有《劳动合同法》第四十条第一项和第二项规定的情形之一，或者劳务派遣单位有《劳动合同法》第四十条第三项、第四十一条规定的情形之一的；

（三）被派遣劳动者因《劳务派遣暂行规定》第十二条规定被用工单位依法退回，劳务派遣单位重新派遣时维持或者提高劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的。

第五十二条 律师应告知劳务派遣单位，有下列情形之一的，劳动合同终止：

- （一）劳动合同期满的；
- （二）被派遣劳动者达到法定退休年龄时或开始依法享受基本养老保险待遇的；
- （三）被派遣劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
- （四）用人单位被依法宣告破产的；
- （五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；
- （六）法律、行政法规规定的其他情形。

第五十三条 律师应告知劳务派遣单位，有下列情形之一的，劳务派遣单位不得解除劳动合同：

（一）被派遣劳动者存在《劳动合同法》第四十二条规定情形之一时，劳务派遣单位不得依据《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同；

（二）被派遣劳动者因《劳务派遣暂行规定》第十二条规定被用工单位退回，劳务派遣单位未重新派遣的，或者重新派遣时降低劳动合同约定条件被派遣劳动者不同意的。

第五十四条 律师应告知劳务派遣单位，劳动合同期满但被派遣劳动者有《劳动合同法》第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止《劳动合同法》第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。

第五十五条 律师应告知劳务派遣单位，劳务派遣单位单方解除劳动合同的，应当事先将理由通知工会。劳务派遣单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求劳务派遣单位纠正。劳务派遣单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。

若劳务派遣单位应当通知而没有事先通知工会的，存在被认定为违法解除的法律风险，但起诉前劳务派遣单位已经补正有关程序的除外。

第五十六条 律师应告知劳务派遣单位，有下列情形之一的，派遣单位应当向劳动者支付经济补偿：

- （一）劳务派遣单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除的；
- （二）被派遣劳动者依照本指引第五十条第二项、第三项解除劳动合同的；
- （三）劳务派遣单位依照本指引第五十一条第二项、第三项解除劳动合同的；
- （四）除劳务派遣单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，被派遣劳动者不同意续订的情形外，派遣单位依照《劳动合同法》第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；
- （五）依照本指引第五十二条第四项、第五项规定终止劳动合同的。

第五十七条 律师应告知劳务派遣单位，派遣单位违法解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，派遣单位应当继续履行。被派遣劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，劳务派遣单位应当依照《劳动合同法》第八十七条规定支付赔偿金。

派遣单位违法解除或者终止劳动合同后，有下列情形之一的，可以认定为劳动合同已经不能继续履行：

- （一）劳动合同在仲裁或者诉讼过程中期满且不存在应当依法续订、续延劳动合同情形的；
- （二）被派遣劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；
- （三）劳务派遣单位被宣告破产的；
- （四）劳务派遣单位解散的，但因合并或者分立需要解散的除外；
- （五）被派遣劳动者已经与其他用人单位建立劳动关系，对完成派遣单位的工作任务造成严重影响，或者经劳务派遣单位提出，不与其他用人单位解除劳动合同的；
- （六）存在劳动合同客观不能履行的其他情形的。

第五十八条 律师应提示用工单位和被派遣劳动者，对于用工单位违法退回被派遣劳动者的，被派遣劳动者能否在主张继续履行劳动合同的同时主张恢复用工关系，在实践中存在争议。倾向性认为，在劳务派遣过程中，被派遣劳动者被用工单位违法退回后，要求恢复与用工单位的用工关系的，裁审实践中难以支持。

第五十九条 律师应提示劳务派遣单位和用工单位，劳务派遣单位因用工单位退回依据不足而解除劳动合同，被裁审机构判令向被派遣劳动者支付赔偿金的，用工单位是否应承担连带责任，实践中意见不一。倾向性认为，用工单位是否应承担连带责任要以劳务派遣协议约定为准。

第六十条 律师应提示劳务派遣单位，劳务派遣单位应在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为被派遣劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。被派遣劳动者应当按照约定，向用工单位或劳务派遣单位办理工作交接。劳务派遣单位应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。劳务派遣单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。

第七章

劳务派遣争议案件代理

第六十一条 律师在接待当事人时，应当与当事人就劳务派遣争议案件所涉相关要点进行有针对性的沟通，初步了解案件基本事实、审查基础证据、了解当事人的基本诉求和潜在需求，在此基础上对案件进行分析并给予意见或建议。

第六十二条 律师应确认涉及劳务派遣争议案件的基本事实包括：

- （一）被派遣劳动者的基本情况；
- （二）劳务派遣单位的基本情况；
- （三）用工单位的基本情况；
- （四）被派遣劳动者与劳务派遣单位之间存在劳动关系并被派遣至用工单位用工的基本事实；
- （五）发生争议的背景、起因、经过以及争议的具体内容；
- （六）当事人对争议解决方向的初步想法。

第六十三条 律师需要了解的基础证据一般包括：

- （一）劳务派遣单位、用工单位和被派遣劳动者的主体适格证据，如营业执照、身份证等；
- （二）被派遣劳动者、劳务派遣单位与用工单位之间签订的劳动合同、劳务派遣协议等文本协议；

- （三）工资条、工资支付凭证或记录；
- （四）社会保险费用缴纳记录；
- （五）用工单位发放的工作证、厂牌、工卡等证件；
- （六）录用通知、入职表、招工表等招用记录；
- （七）考勤记录、钉钉打卡、微信打卡等电子考勤记录；
- （八）能证明属于劳务派遣用工的其他证据，如微信聊天记录、其他劳动者证言等。

第六十四条 律师发现当事人的证据存在缺失或不足，可能导致案件证明困难的，应当及时向当事人进行风险提醒，并告知证据不足可能导致的不利后果。

第六十五条 当事人在咨询后正式委托律师代理劳务派遣争议案件的，律师应通过律师事务所与委托人签订法律服务合同进一步确认具体委托事项，且不得对代理劳动者请求支付劳动报酬、工伤赔偿、给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的案件进行风险代理。

第六十六条 律师应向委托人说明劳务派遣争议案件涉及的有关法律问题，让委托人充分了解自身诉讼权利义务：

- （一）劳务派遣争议案件的受理、审理程序，特别是一裁两审、仲裁前置的特别规定；
- （二）劳务派遣争议案件不同裁审阶段（仲裁、诉讼一审及二审）的审理期限，以及裁审机构因工作安排等因素导致审限可能延长的情形；
- （三）委托人在仲裁诉讼程序中的权利、义务和责任，包括但不限于应当如实说明案情、提供真实有效证据，按规定缴纳相关费用，答辩、举证、质证、出庭，服从仲裁庭或法庭指挥，遵守仲裁或诉讼秩序，履行生效裁判文书（包括裁决、判决、裁定或调解书）等；
- （四）委托人不服仲裁裁决而提出起诉或申请撤销仲裁裁决的法定期间，不服法院一审判决、裁定而提出上诉的法定期间；
- （五）仲裁或诉讼结果受多方面因素影响，律师不能也不会对仲裁或诉讼请求结果提供任何形式的承诺和保证；
- （六）根据案件具体情况，其他需要说明的事务。

第六十七条 劳务派遣争议案件中律师代理被派遣劳动者的，可以分别或同时向劳务派遣单位和/或用工单位提出仲裁或诉讼请求。

第六十八条 劳务派遣争议案件中律师代理劳务派遣单位的，对于因用工单位过错导致的损害，应主张用工单位承担赔偿责任，劳务派遣单位承担连带赔偿责任后可告知按照双方约定另行主张用工单位承担赔偿责任。

第六十九条 劳务派遣争议案件中律师代理用工单位的，对于劳务派遣单位过错导致的损害，可主张劳务派遣单位承担赔偿责任，用工单位承担赔偿责任后可告知按照双方约定另行主张劳务派遣单位承担赔偿责任。

第七十条 律师代理案件过程中，应重点审查案件是否属于劳务派遣争议案件，注意甄别劳务派遣与事实劳动关系、虚假派遣、劳务外包等用工形式，应当注重事实情况调查，梳理案件相关证据，并整理提炼案件争议焦点，便于裁审机构查明事实、归纳争点。

第七十一条 律师代理案件过程中，应综合案件基本情况、证据准备、请求及请求权基础，必要时进行类案检索，并充分考虑不同地区案件相关具体规定的差异性，向委托人提供具体法律分析，法律分析应当考虑到委托人的主观意愿及客观事实情况。

第七十二条 在劳动争议仲裁阶段，劳动者与劳务派遣单位或用工单位发生劳动争议的，劳动者可以向劳动合同履行地、劳务派遣单位所在地或者用工单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第七十三条 在诉讼阶段，劳务派遣争议案件由劳动合同履行地、劳务派遣单位所在地或者用工单位所在地的基层人民法院管辖。各方当事人就同一仲裁裁决分别向有管辖权的人民法院起诉的，后受理的人民法院应当将案件移送给先受理的人民法院。

第七十四条 劳务派遣中工伤案件因与侵权纠纷等其他类型案件产生竞合导致案由及管辖权产生争议的，律师应当根据案件具体情况，向当事人提供分析并确定合适的案由、选择合适的管辖机构。

第七十五条 律师在代理劳务派遣争议案件时，应当结合案件具体情形，对案件时效进行合理判断。律师代理案件时进行时效抗辩的，应当主动在劳动争议仲裁阶段提出，劳动争议仲裁委员会作出裁决后，律师在诉讼阶段又以超过仲裁时效期间为由进行抗辩的，将难以得到支持。

第七十六条 律师在进行案件程序性材料的准备时，应注意对部分可能灭失或者以后难以取得的证据进行证据保全，并通过劳动争议仲裁委员会向所在地人民法院申请。

第七十七条 律师在人民法院阶段才接受劳务派遣争议案件代理的，可以调取和查阅劳动仲裁阶段的卷宗材料如仲裁庭审笔录、双方当事人提供的证据材料等。如果发现委托人的诉讼请求未经劳动争议仲裁前置审理的，律师应当提醒委托人需另行申请仲裁或另寻其他途径处理；如果发现对方当事人诉讼请求未经劳动争议仲裁前置审理的，应当向人民法院及时提出抗辩。

第七十八条 一般情形下，劳务派遣争议案件均应当经过劳动争议仲裁前置程序，但以下情况除外：

（一）依据《劳动争议调解仲裁法》[第十六条](#)规定申请支付令被人民法院裁定终结督促程序后，劳动者依据调解协议直接提起诉讼的；

（二）当事人在经依法设立的调解组织主持下就支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议，双方当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》[第二百零一条](#)的规定共同向人民法院申请司法确认，人民法院不予确认，劳动者依据调解协议直接提起诉讼的。

第七十九条 律师在劳动仲裁阶段代理劳务派遣争议案件的，应按照当事人的意愿，基于案情分析，提出仲裁请求事项，避免遗漏请求导致另行申请仲裁的风险；应按照仲裁请求事项提供相应的证据，避免诉讼阶段因仲裁阶段逾期举证带来的风险。

第八十条 当事人不服劳动争议仲裁裁决，律师在代理案件的时候应当告知当事人可在规定期限内向有管辖权的人民法院提起起诉或申请撤销裁决。律师除了要向人民法院提供劳动仲裁阶段已经提供的证据外，还需要提交仲裁裁决书证明案件经过仲裁前置程序。

第八十一条 律师应告知当事人在人民法院作出一审判决后，若对判决不服，可以在规定期限内向上一级法院提起上诉。案件经二审作出判决或裁定后，为生效的判决或裁定，仍对起不服的，可以申请再审。

第八章

附 则

第八十二条 本指引由上海律协劳动与社会保障专业委员会起草，根据 2025 年 10 月 31 日以前发布的法律、法规及司法解释等相关规定并结合司法实践和律师实务经验编写，非强制性或规范性规定，不具有法律效力，仅供律师在为当事人提供劳务派遣合同纠纷案件相关法律服务时予以参考。



扫一扫，手机阅读更方便